

效的视频广告和特定话术，让老年人相信某商贸有限公司的保健品具有治疗疾病的功能，从而达到将保健品销售给特定群体的目的，被害人基于对被告人上述虚构事实的欺骗行为产生了错误认识，以为交付财物购买保健品能治疗疾病，符合诈骗罪的构成要件，应当定性为诈骗罪。

第二种观点认为构成虚假广告罪。理由是：何某等人为增加从其他公司购进保健品的销量，录制虚假、夸大产品背景、功效等内容的宣传广告视频，并授意安排、培训指导下级经销商通过免费体验艾灸仪器或赠送面条、鸡蛋方式吸引老年人进店，并在店内利用视频授课等方式吸引老年人购买产品，该行为系利用广告对商品作虚假宣传的行为，且达到情节严重标准，应认定构成虚假广告罪。

笔者同意第二种观点，理由如下：

虚假广告罪，是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家广告管理规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。司法实践中，部分办案人员认为，只要存在虚假宣传销售保健品或食品的行为，就应当按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，以诈骗罪定罪处罚，笔者认为这种观点是偏颇的，偏离了该解释的立法本意，办案中要具体分析个案是符合虚假广告罪还是诈骗罪构成要件。具体到本案中，笔者主要从犯罪主观方面、犯罪客观方面、犯罪客体方面的不同进行综合分析，认定被告人构成虚假广告罪。

一是从犯罪客体看，本案侵犯了广告市场管理制度和不特定消费者的合法权益，也侵害了被害人财物所有权。诈骗罪侵犯的是公私财物所有权，虚假广告罪侵犯的是广告市场管理制度和不特定消费者的合法权益。本案中，销售门店利用免费体验艾灸仪器及免费领取鸡蛋、面条等方式吸引不特定老年消费者进店，被告人通过指导门店在老年人体检艾灸过程中通过播放夸大、失实保健品背景及功效的宣传视频以及授课方式吸引其购买产品，这种行为是建立在实

质性市场经营、市场交易上的违规宣传行为，既影响了广告市场的健康发展，扰乱了正常的广告管理秩序，又侵害了消费者的合法权益，因本案各被告人利用虚假广告宣传销售产品定价较高、获利较大，也侵犯到了被害人财物所有权，故应结合其主观目的是非法占有还是非法获利、客观行为是虚构事实还是夸大宣传进行定罪处罚。

二是从犯罪主观方面看，不能认定本案被告人具有非法占有的目的。区分诈骗罪和虚假广告罪的一个重要要件是行为人主观方面是否具有非法占有的目的。诈骗罪的成立要求行为人主观上具有非法占有的目的，一方面表现为行为人妄图不履行任何义务或者不支付任何对价而占有他人财物，类似于“空手套白狼”，不存在实质性的市场经营、市场交易；另一方面表现为行为人还逃避返还骗取的财物，导致被害人的损失无法通过民事、行政途径得到救济。而虚假广告罪的成立要求行为人主观上具有非法获利的目的，而不具有非法占有的目的，其本质特征在于公司以刊登或散发虚伪不实内容的广告，使消费者信以为真，而从事价格与品质不相称的经济交易。因此，如果行为人主观上仅有非法营利的目的，不具有非法占有的目的，则不能以诈骗罪定罪处罚。

具体到本案，首先，涉案产品某胶囊并非被告人自己生产的“三无产品”，而是被告人基于该产品以破壁姬松茸粉、破壁灰树花粉、破壁灵芝孢子粉等为主要原料且具有保健品生产批号和保健功效这种主观认识，而从其他公司采购用以销售的产品，被告人并非意图不履行任何义务或支付任何对价；其次，被告人对该产品作出虚假宣传的目的是促成老年消费者购买产品、达成交易、获取经营利润；最后，被告人销售过程中允许退货，且未发现被告人阻拦退货或者设置高门槛退货条件、给被害人主张权利制造障碍的情形，因此不能认定本案被告人具有非法占有的目的。

三是从犯罪客观方面看，被告人实施的是夸大产品功效的虚假宣传行为而并非完全虚构事实的行为。区分诈骗罪和虚假广告罪的另一个重要要件是犯罪客观行为方面是否采用了隐瞒真相和虚构事实的欺骗方法。诈骗罪采用的是隐瞒真相和虚构事实的欺骗方法，虚构事实的本意是行为人捏造不存在的事实，

从而使受害人产生错误认识、获取被害人的信任并使其处分财产，其虚构的范围不会局限于对产品本身的质量、性能的吹嘘，还包括虚构一切有助于实现其诈骗目的的事实，如通过虚假诊疗、伪造检测报告、夸大被害人的身体实际情况、刻意营造紧急情况等。虚假广告罪采取的是利用广告作夸大、虚假宣传，针对产品本身的效用虚构了部分事实，其行为的“吹嘘夸张”并非“无中生有”，并不能直接从消费者本人的信息或者其他外部条件驱使消费者进行消费。

具体到本案，首先，涉案某胶囊外包装上印有“蓝草帽”保健食品的标识及“保健品不能替代药品”提示语，还明确标注了本品是由破壁姬松茸粉、破壁灰树花粉、破壁灵芝孢子粉为主要原料的保健食品，具有增强免疫力的保健功能。某胶囊出厂成分检测含有粗多糖和三萜类成分，对多种老年疾病具有一定的功效与作用。被告人在制作的广告视频中宣称能够治疗癌症、肿瘤等疾病，更符合夸大功能、虚假宣传的虚假广告行为，鉴于部分虚构事实与客观事实有关联、交叉的关系，不能将其认定为完全虚构事实的行为。其次，老年人进店购买涉案产品的目的不排除是为了强身健体，并非为了治疗疾病，公安机关查找出的几十名被害人，明确陈述患有具体疾病或者为了治疗疾病而购买的人数较少；也不排除是因试服有效果而购买，在案一被害人就是试服改善睡眠后购买；并且本案案发不是因为被害人报案，且绝大多数购买者尚未调查，无相关证据证明被害人是否为根治疾病而购买，进而不能认定老年人

254 中国法院2025年度案例·刑事案例二

是陷入错误认识 而交付财物，因此不能认定被告人采用了隐瞒真相或虚构事实的欺骗方法进行 诈骗。

综上，本案被告人为增加产品销量，制定营销模式、录制宣传视频，并授 意安排、培训指导下级经销商针对不特定老年人群体，利用视频授课等方式对 涉案保健品背景、功效等进行夸大失实的广告宣传，吸引老年人购买，该行为 系利用广告对商品作虚假宣传的行为，且达到情节严重标准，应认定构成虚 假 广告罪。

编写人：山东省日照市岚山区人民法院 刘利红 胡硕文

山东省日照市中级人民法院 张晓燕

明知自己没有实际履行合同的能力而采取
虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，
且数额巨大，认定构成合同诈骗罪

—— 廖某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08刑终156号刑事裁定书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2021年至2022年，时任高速公路公司路政支队贵港大队工作人员的被告人廖某，谎称是为高速公路公司购买烟酒等物品，并以需要等单位报账后再付款为借口，骗取了罗某和李某夫妇、罗某1、杨某和杨某1兄妹、余某、李某、叶某向被告人廖某提供的大量烟酒等物品。之后，廖某便以单位未报得账、董事长调走、新来的财务总监没签字等各种理由拒不支付上述被害人的货款，其所购买的烟酒等物品全部用于廖某个人宴请、送礼等。当罗某和李某夫妇发现被骗后便向公安机关报警。经查，被告人廖某骗取罗某和李某夫妇、罗某1、杨某和杨某1兄妹、余某、李某、叶某共计价值人民币798230元的烟酒等。

【案件焦点】

1. 被告人行为是否构成合同诈骗罪；2. 已进入执行阶段的货款79080元是否还属于诈骗数额。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。本案中，被告人廖某明知自己没有为单位采购烟酒的权利而以某高速公路有限公司的名义，向罗某、罗某1、杨某1、余某等人购买烟酒等物品，并用于其个人宴请或送礼等，又以单位未报得账、人事变动等理由拒不支付货款；其因多起民事纠纷被多人起诉，也均未履行；其收入不足以履行其所负债务；足以认定被告人廖某主观上有非法占有的目的。被告人廖某在履行买卖合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。虽然被告人廖某诈骗罗某1经手的货款79080元已被法院作出民事判决，但并不影响对该起诈骗事实的认定。综上，广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判决如下：

一、被告人廖某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月；

二、责令被告人廖某分别退赔上述损失。

一审宣判后，被告人廖某提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：上诉人廖某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用单位的名义骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。廖某的上诉理由不成立，依法应予驳回。广西壮族自治区贵港市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，有意见认为，被告人没有付款的行为是合同违约行为，应当属于一般的民事纠纷。另有意见认为，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，属于刑

事案件范围。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取较大的公私财物的行为。而合同诈骗，即是在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大。在本案中，不同意见的出现涉及对诈骗罪构成要件中“以非法占有”的主观故意的不同理解与认识。刑法中，非法占有是指明知是他人的财产，而将其转归自己或者第三人“非法所有”并排除权利人所有的一种主观愿望。至于达到何种程度，在不同的犯罪行为中有所差异，需要视不同罪名而准确界定。有的罪名只实际要求占有财物；有的罪名不仅要求实际占有财物，还要求对财物进行使用或者进行事实上或者法律上的处分；有的罪名不仅要求财物占用、使用、处分，还要求造成所有物的灭失或者价值减少。

司法实践中，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的；(2)非法获取资金后逃跑的；(3)肆意挥霍骗取资金的；(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。本案中，被告人廖某明知自己没有为单位采购烟酒的权利而以高速公路有限公司的名义，向罗某、罗某1、杨某1、余某等人购买烟酒等物品，并用于其个人宴请或送礼等，又以单位未报得账、人事变动等理由不支付货款；其因多起民事纠纷被多人起诉，也均未履行；其收入不足以履行其所负债务，属于明显没有履行能力；虽然被告人骗取的不是资金，但是仍属于数额巨大的财物，被告人行为符合认定非法占有目的的情形，并在履行买卖合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究被告人廖某的刑事责任。综上，合议庭认定被害人存在非法占有的目的，行为符合公诉机关所诉合同诈骗罪的构成要件，因此认定该案件的性质为刑事案件。

对于起诉指控被告人廖某诈骗罗某和李某夫妇货款516150元的事实，不仅有被害人陈述，还有送货单、发票及微信聊天记录等证据予以证实。虽然被告

人廖某诈骗罗某1经手的货款79080元已被法院作出民事判决，但并不影响对该起诈骗事实的认定，因此推断被告人廖某的其他诈骗行为属民事纠纷没有法律依据。

实践中，在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。本案中，首先，被告人以帮公司采购的名义，实际骗取了被害人烟酒等财物。作为本案核心的烟酒的所有权，不仅是被告人廖某的犯罪目的，也是其实际诈骗所得财物。其次，从被害人损失的角度来看，被告人廖某没有能力履行合同，补偿被害人的损失。因此从主客观的角度来考虑：主观上，被告人意在非法占有被害人的财产；客观上，被告人虚构帮公司采购的名义，在履行合同过程中，实际骗取的财物。以被告人尚未支付的数额作为本案的诈骗数额，更能反映案件的社会危害性。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院
廖达楼

非房地产销售人员以签订合同形式 骗取“工抵房”定金该如何认定

——何某某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省扬中市人民法院(2023)苏1182刑初143号刑事判决书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2021年11月30日至2022年10月21日，被告人何某某以非法占有为目

的，谎称自己是某公司“工抵房(工程抵押房)”销售的负责人，可以低价销售“工抵房”，骗取成某及房产中介杨某、黄某等人的信任，通过上述人员对外宣传，通过签订房屋买卖合同、伪造印章等方式骗取87名被害人缴纳购房定金人民币3551000元。在合同签订后，被告人何某某以给付“好处费”能加快合同履行等为由，骗取31名被害人给予打点费用、香烟及购物卡等财物，共计价值人民币83393元。工程抵押房简称“工抵房”，是指在某些条件下，房地产开发商为了后续项目的建设或开发，而向银行或房地产的相关行业(如建筑商、材料商等)进行融资、贷款所抵押的该房地产项目中尚未出售的房屋的全部(或部分)的产权或使用权。

【案件焦点】

非房地产销售人员以签订合同形式骗取“工抵房”定金该如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省扬中市人民法院经审理认为：被告人何某某以非法占有为目的，以虚构的身份签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，被告人何某某能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何某某认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，判决如下：

被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；对违法所得予以追缴，发还被害人。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

司法实践中，合同诈骗罪的认定主要围绕合同进行，合同包括书面合同、口头合同及其他形式，应当体现一定的市场秩序，是导致被害人陷入错误认识而做出财产处分的主要原因，以及合同诈骗发生在合同的签订、履行过程中，行为人实施的是与合同内容有关的活动，骗取财物与合同约定相关等问题，已

经基本达成共识。但认定合同诈骗罪，是否还基于扰乱市场经济秩序，要求行

